

0000781-61.2016.8.26.0616

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: José Eugenio Do Amaral Souza Neto

Comarca: Suzano

Foro: Foro de Suzano

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 28/06/2022

... que as drogas se destinavam ao tráfico. Da capitulação inicial, todavia, não merece prosperar unicamente quanto ao crime de associação para o tráfico. Isso porque, embora evidenciado que a dupla praticava o tráfico de drogas, é de se reconhecer que os elementos de convicção são demasiadamente frágeis para se concluir pela natureza estável e permanente da união, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Suzano

2ª Vara Criminal

Av. Paulo Portela, Jd. Paulista, Suzano - 08675-230 - SP

Processo nº:0000781-61.2016.8.26.0616Ré(u):Drielen Maria Silva

ATA DE AUDIÊNCIA

(SISTEMA TELEPRESENCIAL)

(MICROSOFT TEAMS)

(Recomendação CNJ nº 62/2020 e Comunicado CG nº 284/2020)

INSTRUÇÃO, INTERROGATÓRIO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo nº:

0000781-61.2016.8.26.0616

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Boletim de Ocorrência, Inquérito Policial (Flagrante) - 118/2016 - DISE -

Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes de Mogi Das Cruzes, 82/2016 - DISE -

Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes de Mogi Das Cruzes

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Drielen Maria Silva

Réu Preso

Em 28 de junho de 2022, às 13:30h, nesta Cidade e Comarca de de Suzano, Estado de São Paulo, em audiência pelo sistema virtual, sob a presidência do Meritíssimo Juiz de Direito, o Dr(a). José Eugenio Do Amaral Souza Neto, comigo Escrevente ao final nomeado(a), foi aberta a audiência de instrução, debates e julgamento, nos autos digitais do Processo Crime em epígrafe. Realizado o pregão, constatou-se a presença do(a) Promotor(a) de Justiça DR. FELIPE JOSÉ ZAMPONI SANTIAGO, a ré Drielen Maria Silva e seu Defensor Dativo nomeado DR(A). Dimas Cabral Delegá OAB 324876/SP. Presente a testemunha Comum: Fabio Alves dos Santos. Ausente a testemunha Comum: Maisa de Aguiar Galocha, policial civil aposentada, não localizada para intimação pessoal (fls. 257, 272 e 273). A seguir, foi ouvida a testemunha Comum: Fabio Alves dos Santos, havendo desistência homologada, após concordância das partes, da oitiva da testemunha Maisa de Aguiar Galocha. A seguir, foi aceita pelo(a) Dr(a). Defensor(a) a oportunidade de entrevista reservada com o acusado. Ao final, com anuência de seu Defensor, e efetuada a observação determinada no artigo 186 do

Código de Processo Penal, o réu foi interrogado. Em seguida, foi consignado que todas as ocorrências, manifestações, declarações, acareações e depoimentos foram captados e gravados pelo sistema telepresencial, conforme Resolução CNJ nº 354/2020, permanecendo o(s) depoimento(s) e interrogatório(s) anexado(s) ao presente Termo de Audiência Telepresencial. A seguir, dada a palavra às partes, foi dito que não havia diligências a serem requeridas. Em seguida, pelo MM. Juiz foi dito que dava por encerrada a instrução. Apresentadas alegações orais, concedendo-se 20 minutos a(o) Dr(a). Promotor(a) e, após, a(o) Dr(a). Defensor(a). Pelo D. Promotor de Justiça foram apresentadas as seguintes alegações finais: A ré Drielen Maria Silva foi denunciada e está sendo processada como incurso no art. 33, caput, c.c. art. 40, VI, da Lei nº 11.343/06 c.c. art. 29, caput, do Código Penal, e art. 35 da Lei nº 11.343/06, na forma do artigo 69 do Código Penal. Isso porque, no dia 14 de junho de 2016, por volta das 15h30, na Rua Vinte e Seis, nesta cidade e Comarca de Suzano, previamente conluída com o adolescente Anderson Luiz Bonifácio (17 anos - d.n. 28/03/1998), com unidade de desígnios e identidade de propósito, traziam com eles e guardavam, para entrega a consumo de terceiros, 12 (doze) porções de cocaína, acondicionadas em invólucros plásticos, com peso líquido de 11,3g e 11 (onze) porções de Cannabis Sativa L, conhecida popularmente como maconha, acondicionadas em invólucros plásticos, com peso líquido de 14g, drogas estas melhores descritas no auto de exibição e apreensão de fls. 17/18, laudo de constatação de fls. 22/24 e laudo de exame químico toxicológico de fls. 42/46, na forma como são comercializadas, substâncias entorpecentes causadoras de dependência física e psíquica, fazendo-o sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Também porque, nas mesmas condições de tempo e local acima mencionados, em período anterior não precisado, associou-se com o adolescente Anderson Luiz Bonifácio (17 anos - d.n. 28/03/1997), com o fim de praticar, na cidade de Suzano, o comércio ilícito de drogas, crime esse previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06. A ré foi notificada (fls. 250) e apresentou defesa preliminar (fls. 140/141). A denúncia foi recebida em 03 de maio de 2022 (fls. 225/226). Na fase instrutória, foi ouvida uma testemunha arrolada na denúncia. Em seguida, a ré foi interrogada. É o breve relatório. A pretensão punitiva estatal comporta parcial procedência, nos termos da peça inicial acusatória, visto que os elementos de convicção amealhados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa são robustos e conclusivos acerca da responsabilidade criminal da ré, à exceção do crime de associação para o tráfico. Segundo o apurado, a ré e o adolescente Anderson deliberaram por, em conluio estável e permanente, realizar a narcotraficância, o que o faziam, juntos, no supramencionado logradouro, conhecido ponto de venda de drogas. Para tanto, enquanto o adolescente se encarregava das vendas, Drielen se incumbia da guarda dos entorpecentes. Assim foi que, quando do ocorrido, no momento em que estavam no exercício da narcotraficância, foram eles surpreendidos por policiais civis, que para lá se dirigiram visando averiguar denúncia de tráfico de drogas e, após campana, observaram toda a dinâmica das vendas ali entabuladas, especialmente quando o adolescente, por diversas vezes, era abordado por pessoas, delas recebia algo e se dirigia até a acusada, que retirava algo do bolso e entregava ao adolescente, o qual imediatamente repassava o objeto à pessoa que o abordara. Ato contínuo, os agentes públicos os abordaram e, em revista pessoal, apreenderam com o adolescente 02 porções de cocaína e 02 porções de maconha, além da quantia em dinheiro de R\$ 20,00, produto da traficância. Com a ré, por sua vez, apreendeu-se o restante das drogas (10 porções de cocaína e 09 de maconha). Indagados, no local, ambos confessaram a traficância. Os fatos acima narrados, ao final da instrução, restaram devidamente comprovados. Vejamos. A materialidade dos delitos está sobejamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 05), boletim de ocorrência (fls. 13/16), auto de exibição e apreensão (fls. 17/18), laudo de constatação (fls. 22/24), laudo de exame químico-toxicológico (fls. 42/46), laudo de local (fls. 68/74), bem como pela prova oral colhida em Juízo. A autoria, de igual modo, é incontestável. Ouvida em Juízo, a ré negou a acusação. Afirma que foi ao local para comprar drogas; que comprou cocaína e para usar lá; que quem estava traficando era o menor; que ficou lá por umas duas horas; que o conhecia; que

estava em situação de rua na época; que comprou umas doze porções de cocaína; que usou umas três porções; que estava apenas cocaína que sobrou; que nesse período que permaneceu lá o adolescente realizou várias vendas; que não o auxiliou em nenhuma das vendas realizadas nesse período. Sua negativa encontra-se isolada nos autos. De fato, ouvido em juízo, Fábio Alves dos Santos, policial civil, afirma que em averiguação a denúncia de tráfico de drogas fizeram campana, na qual avistaram duas pessoas, uma mulher e um rapaz; que visualizaram pessoas se aproximando, no que o menor se diria até a moça, que pegava algo e entregava a essa pessoa; que fizeram a abordagem e com o menor encontraram quantia em dinheiro e algumas porções de drogas; que, com a ré encontraram o restante das drogas; que o local é conhecido ponto de tráfico; que não se recorda se a denúncia mencionava os traficantes; que, indagados, ambos confessaram a traficância; que não havia investigações prévias sobre a ré e o adolescente. Na mesma linha são as declarações da também policial civil Maisa de Aguiar Galocha, quando ouvida na fase extrajudicial (fls. 08). Como se vê, as declarações dos agentes da força pública, somadas às comprometedoras circunstâncias que permeiam a detenção da acusada demonstram com segurança a posse das drogas e a finalidade mercantil. Nesse ponto, destaque-se para o fato de a ré ter sido presa exatamente no momento em que, juntamente com o adolescente Anderson, praticavam a traficância - o adolescente, por diversas vezes, era abordado por pessoas, delas recebia algo e se dirigia até a acusada, que retirava algo do bolso e entregava ao adolescente, o qual imediatamente repassava o objeto à pessoa que o abordara. Não por acaso, com ela foram encontradas nada menos que 10 porções de cocaína e 09 de maconha, que estavam escondidos no interior de suas vestes, enquanto o restante das drogas e dinheiro estava com o adolescente. Não por outra razão, também, indagados no local, ambos confessaram a mercancia ilícita. Como se observa, a acusada e seu comparsa praticavam a traficância de forma dinâmica e estrategicamente esquematizada, sendo que, enquanto Drielen exercia a função da guarda dos entorpecentes, o adolescente se encarregava das vendas. Não há nos autos qualquer elemento hábil a indicar que os agentes da lei tenham falseado a verdade e, por conseguinte, razão plausível para se afastar o valor probatório dos atos funcionais por elas praticados e dos coesos e seguros relatos testemunhais por eles emanados. As palavras dos policiais, por si só, não podem ser tidas como indignas de fé, uma vez que estes não estão impedidos de depor e, por consequência, não merecem total credibilidade, desde que não provada má-fé ou abuso de poder, o que vale dizer que a inidoneidade não pode ser genérica, mas sim específica e demonstrada em cada caso. E, na hipótese dos autos, tais testemunhas sequer foram contraditadas. Nesse sentido: "O testemunho policial goza de presunção de credibilidade (TJGO, ApCrim.14.435, 2 Cam., rel.Des.Remo Palazzo, j.23-2-1995, RT 716/479). Para restar destituído de valor probante é necessário a demonstração de motivo sério e concreto, não sendo suficiente mera alegação desacompanhada de elemento de convicção." "A prova testemunhal obtida por depoimento de agente policial não se desclassifica tão-só pela sua condição profissional, na suposição de que tende a demonstrar a validade do trabalho realizado; é preciso evidenciar que ele tenha interesse particular na investigação, tal como ocorre nas demais testemunhas, que suas declarações não se harmonizem com outras provas idôneas." (STF, HC 74.522-9/AC, 2 T., rel. Min. Maurício Corrêa, DJU de 13-12-1996, p.50167). "O depoimento vale não pela condição do depoente, mas pelo seu conteúdo de verdade. Estando em harmonia com as demais provas dos autos, não há razão para desprezá-lo, apenas porque prestado por policial". (TJSP, Ap Crim 175.325-3, 1 Cam. Crim.j. 6-2-1995, rel.Des. Jarbas Mazzoni, JTJ 169/313). Com efeito, a quantidade e variedade de entorpecentes, a forma como se encontravam acondicionados (porções individualizadas e prontas para a comercialização), aliados às circunstâncias da detenção, o dinheiro apreendido e a confissão informal, demonstram que as drogas se destinavam ao tráfico. Da capitulação inicial, todavia, não merece prosperar unicamente quanto ao crime de associação para o tráfico. Isso porque, embora evidenciado que a dupla praticava o tráfico de drogas, é de se reconhecer que os elementos de convicção são demasiadamente frágeis para se concluir pela natureza estável e permanente da união, mormente porque nenhum ato de exteriorização nesse sentido (v.g. apreensão

de petrechos de fabricação, notícia de envolvimento anterior em conluio). Portanto, a condenação da ré é de rigor. No que tange a dosimetria da pena, na terceira fase, de se computar a causa de aumento de pena do art. 40, VI, da Lei nº 11.343/06. No tocante ao regime de cumprimento de pena, em razão da primariedade e demais circunstâncias favoráveis, reputo viável a fixação do regime prisional aberto. Pelas mesmas razões, reputo viável, também, a conversão da pena corporal em restritivas de direitos. Permanecendo o mesmo panorama fática, cabível outrossim, a concessão do direito de recorrer em liberdade. Diante do exposto, requeiro a condenação da ré nos termos da denúncia, como medida de Justiça. Pelo D. Defensor foram apresentadas as seguintes alegações finais: A denunciada, encontra-se incurso nas sanções do crime prescrito no art. 33 da lei nº 11.343/06, posto que foi presa em flagrante, sob acusação de estar praticando traficância de substância entorpecente. Contudo, conforme se observa dos autos, as drogas que foram encontradas com a ré, eram para uso pessoal, afirmou ser usuária de drogas e que havia adquirido para uso. O fato de a ré estar próxima do local do tráfico não quer dizer que ele tenha envolvimento com o ilícito. A denunciada é apenas um usuário de drogas que estava no local tão-somente para comprar e consumir a substância entorpecente. Durante audiência de instrução realizada por este Douto Magistrado, através dos depoimentos dos policiais, foi constatado que o denunciado foi encontrado no local destinado para usuários – fato conhecido pela polícia. Verifica-se que não há nenhuma prova capaz de imputar a denunciada a prática do crime constante na denúncia. Em síntese, são os fatos. **MÉRITO DA ABSOLVIÇÃO NECESSÁRIA.** Conforme informações dos autos percebe-se a ausência de qualquer prova que a denunciada tinha a intenção de vender a droga apreendida no local do crime. Em seu interrogatório, a denunciada é categórica ao afirmar que é apenas usuário habitual e jamais se envolveu na mercancia de qualquer entorpecente. Diante da insuficiência das provas, não há como imputar a denunciada a autoria pela prática de tráfico de drogas, de forma que, nos termos do art. 386, V e VII do CPP, o juiz deverá absolvê-lo. As provas trazidas aos autos claramente ratificam o envolvimento da denunciada somente como usuário, estando provado que este não concorreu de forma alguma para a prática do crime constante na denúncia. Caso não seja este o entendimento do MM. Juízo, torna-se incontestável então a necessidade de aplicação do princípio do in dubio pro réu, uma vez que certa é a dúvida acerca da culpa a ele atribuída com relação à acusação de Tráfico de Drogas, pois o Réu não foi encontrado em atividade de traficância. Destarte, diante da insuficiência probatória, posto que a acusação não conseguiu demonstrar que os fatos efetivamente ocorreram para que pudessem imputar a prática delituosa ao denunciado, não conseguindo, conseqüentemente, demonstrar que fora a conduta do denunciado que causou a lesão ao bem juridicamente protegido, que ressaí dos autos, a pretensão punitiva merece ser julgada improcedente. Nesse sentido, temos o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul: **APELAÇÃO CRIME. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO. IN DUBIO PRO REO. ART. 386, VI, DO CPP.** A condenação do réu exige prova robusta da autoria do fato delituoso que lhe é imputado. Remanescendo dúvida, impõe-se a absolvição, com fundamento no art. 386, VI, do CPP. Sendo assim, a denunciada deve ser ABSOLVIDA, com fundamento no art. 386, inciso V do Código de Processo Penal, por não haver qualquer prova de que o Sr. Peterson tenha concorrido para o tráfico de drogas. Se este não for o entendimento, que seja ABSOLVIDO nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, devida inexistência de provas suficientes que ensejem sua condenação pela figura do art. 33, caput, da Lei 11.343/06. **DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA USUÁRIO.** Em seu interrogatório, a denunciada explica o motivo de estar no local onde foi preso. Trata-se de um usuário, que estava em local “destinado para usuários” definido pelos próprios traficantes, fato este de conhecimento da polícia. Numa simples análise do art. 28 e do art. 33 da lei nº 11.343/06 é notório que a vontade do agente e a destinação para uso pessoal da denunciada, o simples indício de materialidade do crime de tráfico de drogas não é argumento suficiente para a condenação pelo delito do art. 33 da referida lei. Para iniciar a ação penal bastam indícios mas, para condenar é necessária prova. Conforme se observa do exposto, resta por comprovada a situação da denunciada como usuário de drogas,

conduta elencada no art. 28 da Lei de Drogas, e não a de traficante, conforme aduzido na denúncia. Não há prova nos autos que, de acordo com a análise dos depoimentos, do local do fato, das condições em que se desenvolveu a ação, das circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do Réu, cheguem à certeza plena de que a prática do fato era realmente tráfico de drogas, razão que demonstra caso típico de desclassificação. Do exposto, caso Vossa Excelência não vislumbre a ideia da absolvição, requer que seja desclassificada a conduta prevista na denúncia para a conduta prevista no art. 28, da lei 11.343/06. Absolver a denunciada, pela ausência de provas de que este concorreu para a prática do crime, nos termos do art. 386, V do CPP; Caso não seja este o entendimento, que seja absolvido por não existir prova suficiente para a condenação, com base no art. 386, VII, do CPP; Pelo princípio da eventualidade, que seja desclassificada a conduta para a prática do art. 28 da lei 11.343/06, por existirem elementos suficientes para a afirmação de que a denunciada é usuário de drogas. O delito previsto no artigo 40, inciso II da lei 13.343/06, não merece prosperar haja vista que, a denunciada estava usando drogas no local. Outrossim, devemos destacar que não há provas nos autos de que a finalidade do local de tráfico seria vender drogas. Sendo assim, requer o afastamento da majorante supracitada, considerando a falta de dolo da agente na referida conduta. Por necessário, ad argumentum, caso Vossa Excelência entenda pela condenação, requer que a pena seja fixada no mínimo legal e que o denunciado possa apelar em liberdade nos termos do art. 283 do CPP, por preencher os requisitos objetivos para tal benefício.. As alegações orais foram reduzidas em arquivo audiovisual. A seguir, concluídos os debates, pelo Meritíssimo Juiz foi proferida a seguinte sentença: "Vistos.

Trata-se de ação penal pública movida pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais e com base no incluso inquérito policial, em face de DRIELEN MARIA SILVA (nascida em 28/03/1997), devidamente qualificada nos autos, dada como incurso nas penas do art. 33, caput, c.c. art. 40, VI, e do art. 35, todos da Lei nº 11.343/06, na forma do art. 69, CP.

Consta da denúncia que, em 14/06/2016, por volta das 15h30, na Rua Vinte e Seis, neste Município e Comarca de Suzano, envolvendo o adolescente A.L.B., a Ré traria consigo e guardaria, para entrega ao consumo de terceiros, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, 11 porções de maconha (14g) e 12 porções de cocaína (11,3g).

Consta, também, que, nas mesmas condições de tempo e local e em período anterior não precisado, a Ré teria se associado ao adolescente A.L.B. para o fim de praticar, neste Município e Comarca de Suzano, o comércio ilícito de drogas, crime previsto no art. 33, Lei nº 11.343/06.

Em 15/06/2016, em audiência de custódia, foi homologada a prisão em flagrante e concedida a liberdade provisória à Ré, com cautelares alternativas à prisão (fls. 49/51).

Em 21/10/2016, foi determinada a intimação da Ré para oferecer defesa prévia (fls. 76).

Ante o mandado negativo (fls. 89), o Ministério Público requereu a decretação da prisão preventiva (fls. 93), o que foi determinado em 19/12/2016 (fls. 97).

Apresentada defesa prévia (fls. 140/141).

Em 28/01/2018, foi cumprido o mandado de prisão preventiva (fls. 161) e, em 03/04/2018, foi revogada a prisão preventiva, sendo concedida liberdade provisória, com cautelares alternativas (fls. 165/168).

Novamente não localizada a Ré para intimação, por duas vezes (fls. 184 e 193), o Ministério Público requereu a decretação da sua prisão preventiva (fls. 196/197), o que foi novamente determinado em 04/11/2019 (fls. 199/200).

Em 26/04/2022, foi cumprido o mandado de prisão preventiva (fls. 217/219).

Em 03/05/2022, foi recebida a denúncia e designada audiência de instrução e julgamento (fls. 225/226)

Durante a instrução, foi ouvida testemunha e interrogada a Ré.

Em suas alegações finais, o Ministério Público pugna pela parcial procedência da ação, apenas pelo crime de tráfico de drogas, com a causa de aumento do tráfico com

adolescente, admitindo a fixação do regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
Por sua vez, a Defesa pede a absolvição do Réu por falta de provas.
Subsidiariamente, requer a desclassificação para o crime tipificado no art. 28, Lei nº 11.343/06.

É o relatório.

A pretensão acusatória deve ser julgada parcialmente procedente.

Tráfico de drogas (art. 33, caput, Lei nº 11/343/06)

A materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 05), pelo boletim de ocorrência (fls. 13/16), pelo auto de exibição e apreensão das drogas e do dinheiro (fls. 17/18) e pelo laudo de exame químico-toxicológico definitivo (fls. 42/46), produzido na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Da mesma forma, a autoria é indubitosa, ante a prova produzida em audiência.

O policial civil Fábio Alves dos Santos declarou que recebeu uma denúncia a respeito de tráfico de drogas no local, conhecido ponto de comércio ilícito de entorpecentes. Foi ao local e viu a Ré e o adolescente parados, lado a lado. Uma pessoa se aproximou deles, entregou algo ao adolescente, que foi até a Ré e pegou algo, entregando a essa pessoa, que foi embora. Fizeram a abordagem e, com o adolescente, encontraram dinheiro e uma pequena quantidade de drogas e, com a Ré, mais drogas. Indagados, ambos confessaram de pronto a traficância. Foram apreendidas porções de maconha e cocaína. Não conhecia os Réus de abordagens anteriores, tampouco tem conhecimento sobre investigação envolvendo os dois. Em seu interrogatório, a Ré negou a prática delitiva. Disse que foi ao local e comprou 12 porções de cocaína do adolescente, para uso próprio, e permaneceu ali por cerca de duas horas, para "fazer volume". Estava em situação de rua e encontrava o adolescente naquele ponto de tráfico, ocasionalmente. Não estava com maconha, pois não usa essa droga. Não ajudou o adolescente em momento algum. Em delegacia, permaneceu em silêncio (fls. 10).

Ou seja, não resta dúvida que a Ré, juntamente com o adolescente, na data, horário e local dos fatos narrados na denúncia, trazia consigo droga, para fins de venda a terceiros, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, a caracterizar a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, Lei nº 11.343/06).

A versão da Ré em juízo é absolutamente inverossímil. É fato público e notório que usuários ficam o menor tempo possível no ponto de compra e venda de entorpecentes, justamente para não serem confundidos com traficantes e presos. Permanecer duas horas nesse local, para "fazer volume", não faz sentido.

Da mesma forma, não há explicação plausível para uma pessoa em situação de rua, como a Ré diz estar, comprar 12 porções de cocaína para uso próprio, já que o custo dessa aquisição é relativamente alto para uma pessoa em tamanha vulnerabilidade. Ademais, o policial militar foi claro em dizer que observou a Ré auxiliando o adolescente na transação com um usuário, o que é muito mais lógico, estando provada, assim, a acusação da prática de tráfico de drogas narrada pelo Ministério Público.

Impossível a desclassificação da conduta para o crime previsto no art. 28, Lei nº 11.343/06, pois demonstrado que a Ré trazia consigo droga para comercializar a terceiros, conforme acima exposto, o que caracteriza o crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, Lei nº 11.343/06).

O fato ainda é antijurídico, posto que verberado pela lei penal, e não foi alegada nem restou provada nenhuma causa excludente de antijuridicidade dentre aquelas elencadas no art. 23, CP.

A Ré é maior de 18 (dezoito) anos, penalmente responsável (imputável), consciente da ilicitude dos fatos que praticou e lhe era exigida conduta diversa da que exerceu. Presente, destarte, sua culpabilidade.

Diante disso, a condenação é a medida que se impõe.

Inexistem privilégios ou qualificadoras a serem apreciados. As circunstâncias judiciais, agravantes e atenuantes serão apreciadas quando da dosimetria da pena. Presente a causa de aumento de pena prevista no art. 40, VI, Lei nº 11.343/06, pois o crime envolveu o adolescente A.L.B., que atuava junto com a Ré na traficância, conforme os depoimentos colhidos nesta audiência. Também está presente a causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, Lei nº 11.343/06, eis que a Ré era primária e de bons antecedentes (fls. 77/79) e não há prova de que se dedique a atividades criminosas ou integre organização criminosa.

Associação para o tráfico (art. 35, Lei nº 11.343/06)

Ausente prova da existência desse crime.

Não consta dos autos qualquer prova que a Ré e o adolescente tenham se associado para, reiteradamente, traficar drogas. Nenhuma testemunha declarou nada nesse sentido, Ré e adolescente silenciaram em delegacia e, em juízo, a Ré negou esse crime. Nem mesmo a forma como foi realizado o flagrante – na via pública – e a quantidade e variedade de drogas indica esse suposto vínculo.

Não basta que o tráfico de drogas seja cometido em concurso de agentes para que se caracterize o crime do art. 35, Lei nº 11.343/06, sendo necessária prova da associação estável e reiterada, conforme pacífica jurisprudência:

“Apelação. Crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico. Sentença condenatória. Recurso das defesas. 1. Quadro probatório suficiente para evidenciar a responsabilidade penal dos acusados pelo delito previsto no artigo 33 “caput”, da Lei nº 11.343/05. 2. O delito estatuído no artigo 35, da Lei nº 11.343/06 reclama uma associação dotada de estabilidade, que não se confunde com o concurso de agentes. Panorama não configurado na hipótese. Absolvição decretada em relação a esta segunda acusação. 3. Não reconhecimento da participação de menor importância quanto a Leonardo, nem a incidência da regra prevista no artigo 41, da Lei nº 11.343/06. 4. Aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, par. 4º, da Lei nº 11.343/06, com diminuição do “quantum” em 1/3, em razão da quantidade, diversidade e natureza das drogas, com relação ao acusado Leonardo. 5. Penas redimensionadas. 6. Fixação dos regimes iniciais (para a pena privativa de liberdade) fechado (Lucas) e semiaberto (Leonardo), sem substituição por penas restritivas de direito. Recurso de Lucas provido. Apelo de Leonardo parcialmente provido.” (TJSP, Apelação nº 1500078-78.2020.8.26.0628, Rel. Des. Laerte Marrone, 14ª Câmara de Dir. Criminal, j. 31/05/2022 – destaques acrescentados)

“APELAÇÕES CRIMINAIS - Tráfico ilícito de drogas e associação para o tráfico em concurso material - Art. 33, caput e art. 35, caput, ambos da Lei 11.343/06 - Autoria e Materialidade comprovadas quanto ao tráfico de drogas - Palavra dos Policiais Civis - Validade - Precedentes - Autoria evidenciada pelas circunstâncias da prisão - Destinação mercantilista do entorpecente apreendido evidenciada pelas circunstâncias fáticas da prisão - Insubsistente a alegação de ausência de provas ou a desclassificação - Absolvição quanto ao delito de associação - Necessidade - Ausência de provas da estabilidade e permanência - A associação para o tráfico não se confunde com o concurso eventual de pessoas - Pena - Dosimetria - De rigor a fixação da pena-base no mínimo legal, eis que a quantidade e variedade de entorpecentes são circunstâncias aptas a afastar a imposição do redutor - Acusados que faziam da prática de delitos, sobretudo o tráfico, meio de vida - Regime inicial fechado - Adequado ao caso concreto - APELOS PARCIALMENTE PROVIDOS.” (TJSP, Apelação nº 1503734-85.2021.8.26.0344, Rel. Des. Silmar Fernandes, 9ª Câmara de Dir. Criminal, j. 30/03/2022 – destaques acrescentados)

Sendo assim, de rigor a absolvição da Ré por essa imputação, nos termos do art. 386, II, CPP.

Passo à dosimetria da pena.

No que se refere à pena base, a natureza das drogas é neutra, eis que apreendidas duas variedades; mas a quantidade é pequena, o que conta em favor da Ré. A Réu

ostenta bons antecedentes, pois, além deste processo, nada consta em sua folha de antecedentes (fls. 77/79). Favorável, portanto, essa circunstância judicial. As demais circunstâncias judiciais são neutras.

Dessa forma, nos termos dos arts. 42, Lei nº 11.343/06 e 59, CP, a pena base deve ser fixada no mínimo legal de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias multa.

Na segunda fase, verifica-se a atenuante da menoridade relativa (art. 65, I, CP) – eis que a Ré era menor de 21 (vinte e um) anos quando dos fatos narrados na denúncia. Não há agravante.

Dessa forma, impossível a redução da pena abaixo do mínimo legal nesta fase, conforme o disposto na Súmula nº 231, STJ, mantenho a pena base como pena provisória.

Conforme exposto acima, há a causa de aumento prevista no art. 40, VI, Lei nº 11.343/06 e a causa de diminuição do art. 33, § 4º, do referido diploma legal.

Como o crime ocorreu envolvendo apenas um adolescente, de rigor a exasperação da pena provisória em 1/6, fixando-se a pena em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias multa. Em seguida, reduzo a pena em 2/3, restando a pena definitiva em 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 194 (cento e noventa e quatro) dias multa, sendo que o valor do dia-multa será 1/30 (um trigésimo) do valor do salário mínimo da época dos fatos, haja vista não haver prova da renda da Ré.

Para fixação do regime inicial, adoto o entendimento do STF no julgamento do HC nº 111.840/ES que, em 27/06/2012, reconheceu incidentalmente a inconstitucionalidade do § 1º do art. 2º, Lei nº 8.072/90. Assim, nos termos dos arts. 33, §§ 2º e 3º, e 59, CP e 42, Lei nº 11.343/06, sendo a Ré primária e havendo circunstâncias judiciais neutras e favoráveis, deverá cumprir a pena privativa de liberdade que lhe foi aplicada inicialmente em regime aberto.

Em face do disposto no art. 33, § 4º, Lei nº 11.343/06, e de acordo com a Resolução nº 05/2012 do Senado Federal, que aplicou o efeito vinculante à declaração de inconstitucionalidade da expressão “vedada a conversão em penas restritivas de direitos” constante do citado dispositivo legal, substituo, na forma do art. 44, CP, a pena privativa de liberdade aplicada por uma restritiva de direito, a saber: prestação pecuniária, no valor de 01 (um) salário mínimo.

Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a pretensão acusatória, para absolver a Ré da imputação da prática do crime do art. 35, Lei nº 11.343/06, nos termos do art. 386, II, CPP; e para condenar a Ré DRIELEN MARIA SILVA como incurso no art. 33, § 4º, c.c. art. 40, VI, ambos da Lei nº 11.343/06, às penas de 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por prestação pecuniária de um salário mínimo, e 194 (cento e noventa e quatro) dias multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Ante a pena ora aplicada, concedo a Ré o direito de recorrer em liberdade, expedindo-se imediato alvará de soltura.

Deixa-se de estabelecer valor mínimo para reparação civil, dada a ausência de ofendido (art. 387, IV, CPP).

Expeça-se certidão de honorários em favor da Defesa Dativa nomeada.

Com o trânsito em julgado:

- a. comunique-se o Tribunal Regional Eleitoral e ao IIRG;
 - b. remetam-se os autos ao Contador Judicial para o cálculo da pena de multa e custas;
 - c. intime-se a Ré para o recolhimento da pena de multa, no prazo de 10 (dez) dias;
 - d. expeça-se guia de recolhimento definitivo, com a conclusão para designação de audiência admonitória;
 - e. proceda-se ao encaminhamento dos bens cujo perdimento foi decretado em favor da União, conforme determina o art. 63, Lei nº 11.343/06;
 - f. procedam-se às demais diligências e comunicações determinadas no Código de Normas da Egrégia Corregedoria-Geral de Justiça.
- Condene a Ré ao pagamento das custas e despesas processuais, observada a gratuidade de justiça, ora concedida.

PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. INTIMEM-SE."

Em seguida, pelo Ministério Público foi dito que não recorre da sentença. Pela Ré foi dito que não recorre da sentença. Pela Defesa Técnica, foi dito que recorre da sentença. Na sequência, pelo MM. Juiz, foi concedido o prazo de 08 (oito) dias para oferecimento das razões de apelação pela Defesa, que sai, desde já, intimado(a). Certifico, desde logo, o trânsito em julgado para Ministério Público e para a Ré. NADA MAIS. Para constar, lavrei este que lido e achado conforme, vai devidamente assinado digitalmente pelo(a) MM(^a). Juiz(a) e por mim, Escrevente. Certifico as presenças dos mencionados na presente ata e deixo de cumprir o disposto no artigo 145, III das NSCGJ. O referido é verdade e dou fé. Dou as partes presentes por intimadas. Eu, Daniel Kazuhiko Kuruiwa, Escrevente Técnico Judiciário, digitei e subscrevi.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA